

1517007-57.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517007-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517007-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205115/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26419146 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2205115 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE XAVIER DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

RAFAEL HENRIQUE TOLEDO e FELIPE XAVIER DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 28 de julho de 2022, por volta das 14h59, na Av. Michihisa Murata, altura do nº 200, Freguesia do Ó, São Paulo - SP, traziam, transportavam e expunham à venda, para fins de tráfico, 83 porções de cocaína, pesando 28,8g, 20 porções de maconha, pesando 20,8g, e 45 porções de crack, pesando 2,7g, além da quantia de R\$341,00 (trezentos e quarenta e um reais) em espécie e notas trocadas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Em 12 de agosto de 2022 houve a determinação para a notificação dos réus e

apresentação da defesa prévia (fls. 82/83).

Os réus foram notificados (fls. 136 e 138) e ofertaram suas defesas preliminares, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 141). A denúncia foi recebida (fls. 143) e os réus devidamente citados na presente data.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e uma declarante arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida os réus interrogados. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu Rafael nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a elevação da pena base pela natureza das drogas, a não aplicação do redutor e a fixação do regime inicial fechado. Pleiteou a absolvição de Felipe por ausência de provas.

A Defesa requereu a absolvição por ilicitude da prova. Subsidiariamente, acompanhou o pedido de absolvição por insuficiência de provas com relação a Felipe. Em caso de condenação, postulou fixação das penas no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente em parte.

No que tange aos depoimentos, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando adentraram no local dos fatos, conhecido ponte de tráfico, que é uma viela, com entrada/saída de ambos os lados. No dia dos fatos, adentraram pela entrada da avenida, diferentemente do que costumavam fazer anteriormente. Visualizaram os dois réus, sendo que Rafael tinha em suas mãos uma sacola e Felipe gritou “olha a viatura” (segundo o policial Delcio) e “moio” (segundo o policial Fernando). Após dispensar a sacola, ambos começaram a caminhar rapidamente na direção da viatura. Havia apenas os dois no local. Eles foram abordados e a sacola dispensada foi recuperada. Dentro da sacola havia porções fracionadas de crack, cocaína e maconha. Havia também certa quantia em dinheiro (cerca de R\$ 340 segundo o policial Fernando), a qual estava em poder de Rafael, segundo Delcio e com Felipe, segundo Fernando. O dinheiro estava em notas trocadas. O policial Delcio não os conhecia anteriormente. O policial Fernando disse que já os tinha abordado anteriormente, esclarecendo que chegou a falar para Rafael que havia denúncia anônimas contra ele, mas eles não foram presos, porque nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Não houve qualquer problema nas abordagens anteriores, tampouco na abordagem do dia dos fatos. Rafael confessou a prática delitiva e Felipe negou, afirmando que apenas estava passando. O policial Delcio disse que quando os réus já estavam na viatura populares comparecerem e alegaram que Felipe seria o gerente do tráfico.

Ana Maria, genitora de Rafael, afirmou que não presenciou o momento da prisão de seu filho, tendo sido avisada pela namorada dele por meio de um telefonema. A declarante dirigiu-se ao distrito policial, não tendo ido ao local da prisão. Não conhecia Felipe anteriormente, sendo que apenas o conheceu no dia dos fatos. Seu filho saiu de manhã, por volta das 8:30 horas afirmando que “ia ver um negócio”, sem especificar. Não mais teve contato com ele até saber da prisão. Seu filho não estava trabalhando na época.

O réu Rafael, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que tinha uma dívida, por conta de sua prisão anterior, motivo pelo qual voltou a traficar para pagá-la. Felipe mora na rua e estava apenas passando, sendo que lhe pediu um cigarro. Logo em seguida foram abordados.

O réu Felipe, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que reside na rua dos fatos e que estava passando pelo local quando avistou Rafael sentado e pediu a ele um cigarro. Logo em seguida foram abordados. Quem gritou “moio” foi outro indivíduo.

Considera-se que a abordagem policial levada a cabo nestes autos seja regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos policiais ouvidos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2º, do Código de

Processo Penal. Ora, os policiais narraram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, disseram que avistaram o réu Rafael portando uma sacola, que ele dispensou ao perceber a aproximação da viatura, bem como escutaram alguém procedendo ao alerta "moio". Considera-se que tais elementos sejam suficientes para configurar a fundada suspeita legalmente prevista para dar ensejo à abordagem e consequente revista pessoal ao réu.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu Rafael, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: a variedade, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; a sacola onde estavam os entorpecentes foi vista pelos policiais em poder de Rafael, o qual a dispensou quando percebeu a presença da viatura; a ausência de demonstração que as drogas destinavam-se para seu consumo próprio, tendo em conta a variedade de drogas e a quantidade de porções, além do fato de que não possuía qualquer apetrecho destinado ao uso dos entorpecentes; apreensão de dinheiro em notas trocadas; a confissão do réu Rafael. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que as pequenas contradições havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência.

Como apontado acima, não há que se falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, haja vista a quantidade de porções e variedade de drogas, prontas para venda e consumo, devendo-se ter em conta, também, os demais aspectos, como as circunstâncias da prisão em flagrante, que não se coadunam com o mero porte para consumo pessoal, não sendo incomum, infelizmente, o tráfico de drogas realizado por usuários para manutenção do próprio vício.

Ainda que se argumente sobre o fato dos policiais não terem presenciado a comercialização, irrelevante tal aspecto, haja vista que se trata de crime de conteúdo múltiplo ou variado, sendo que no presente caso trazia as porções das

drogas supramencionadas.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 114/116), também a corroborar o contido na denúncia.

Por outro lado, o mesmo não pode ser confirmado em relação ao corréu Felipe, porquanto os policiais não trouxeram maiores elementos que comprovassem sua efetiva participação na empreitada criminosa, eis que o fato de ter gritado sobre a aproximação da viatura, por si só, não configura o ilícito tratado na denúncia, tampouco foi surpreendido em poder de qualquer entorpecente ou dinheiro, motivo pelo qual, subsistindo dúvida razoável, de rigor a sua absolvição. Ademais, a alegada informação de que haveria populares imputando a Felipe a gerência do tráfico no local não foi formalizada, segundo informado pelo policial Fernando, e os populares que teriam procurado os policiais no dia da prisão não foram identificados, de modo que tal informação não tem qualquer validade judicial. Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima referidos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza excepcionalmente nociva de parte dos entorpecentes (cocaína e crack), em diversas porções destinadas à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo, razão pela qual majoro a pena-base do réu em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Na segunda fase, ausentes agravantes, as penas retornam ao mínimo legal, eis que presente a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável a redução aquém do mínimo nesta fase, conforme Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, as penas devem ser reduzidas em 2/3, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, como ocorre no presente caso, tornando-se definitivas em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Anoto que o réu é tecnicamente primário, pois os outros dois feitos em que responde por igual delito ainda não tiveram trânsito em julgado. Segundo entendimento recentemente pacificado pelo E. STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, processos-paradigma do Tema n. 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, firmou-se a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06

Ante a primariedade do réu e a quantidade de pena, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL HENRIQUE TOLEDO, por infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Outrossim, ABSOLVO o réu FELIPE XAVIER DOS SANTOS da infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apesar de os feitos em andamento não impedirem a incidência do redutor, entende-se que não autorizem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois os requisitos subjetivos não se encontraram preenchidos. Com efeito, o próprio réu confirmou que apenas estava praticando o tráfico para pagar dívida

anterior derivada de sua prisão e perda de drogas. Os fatos ocorreram exatamente no mesmo local (feito da 27ª Vara Criminal) e o réu tem condenação por igual delito em local que fica a 1,7 km do local dos fatos (feito da 14ª Vara Criminal), sendo que tais circunstâncias apenas referendam a conclusão pela inadequação da substituição. Ademais, também deve-se levar em consideração os motivos que levaram à elevação da pena-base, de modo que se entende que não estejam presentes os requisitos legais para se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante da pena fixada e o regime prisional, entendo ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, defiro ao réu Rafael o direito de recorrer em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura para Rafael e Felipe.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 143.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei.

Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

P.R.I.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA